

1500283-08.2022.8.26.0024

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael

Comarca: Andradina

Foro: Foro de Andradina

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... anteriores de possível prática de tráfico de drogas e da também da propriedade de tal arma.

O réu, na delegacia, confessou os fatos, dizendo que após o falecimento de seu pai ficou com a arma (fl. 08). Em juízo, trouxe versão pouco crível, de que apenas teria assumido a propriedade da arma para sua avó não ser presa. Anoto que o réu é reincidente (e foi efetivamente preso em razão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Andradina

Foro de Andradina

3ª Vara

Rua Paes Leme, 2052, Andradina-SP - cep 16901-110

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500283-08.2022.8.26.0024 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500283-08.2022.8.26.0024

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2046698/2022 - DEL.POL.CASTILHO, 23093737 - DEL.POL.CASTILHO, 164/22/102 - DEL.POL.CASTILHO, 2046698 -

DEL.POL.CASTILHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DENILSON DE FRANÇA MARQUES e outros

Réu Preso

O Ministério Público ofereceu denúncia contra DENILSON DE FRANÇA MARQUES imputando-lhe a prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de numeração suprimida (Art. 16 § 1º, IV da LEI 10.826/03).

Narra a denúncia que no dia 17 de fevereiro de 2022, por volta das 11h15min, na Rua Raimundo Pinto da Costa, nº 292, Laranjeiras, na cidade de Castilho, nesta comarca de Andradina, o réu qualificado a fls.08, 33/35 e 51/52 dos presentes autos, possuía uma arma de fogo - um revólver, de calibre 38, da marca "S&W", com numeração suprimida - desmuniada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 09 de março de 2022, em decisão de fl.123. O réu foi citado e apresentou resposta à acusação de fl.179/181.

Após regular instrução, o Ministério Público manifestou-se pela condenação, entendendo demonstradas a materialidade e autoria do delito imputado, pugnando entretanto pela desclassificação (fl. 231); a d. Defesa, por sua vez, requereu a absolvição por atipicidade da conduta, pois a arma ostentava numeração íntegra e

pertencia ao pai do acusado, e, subsidiariamente, desclassificação do delito, bem como reconhecimento da confissão do acusado e outros pedidos sobre eventual aplicação da pena e regime de cumprimento.

É o relato do necessário. Fundamento e DECIDO.

Inexistem nulidades ou irregularidades a serem sanadas. O feito tramitou regularmente. Não foram arguidas preliminares ou questões prejudiciais aptas a impedir o prosseguimento da marcha processual, razão pela qual passo à análise do mérito da lide.

Após detida análise das provas produzidas e sopesadas as alegações das partes, conclui-se pela parcial procedência da acusação, com a condenação do réu pelo delito de posse ilegal de arma de fogo (art. 12 do Estatuto do Desarmamento). Com efeito, a ocorrência do delito foi demonstrada pelos elementos da investigação (APF de fl.01 e boletim de ocorrência de fls.10/14, termo de depoimento de fls.02/03, termo de declarações de fls.04/07, imagem de fl.17 e 67/74, autos de exibição e apreensão de fls.19/20, laudos periciais de fls.143/155 e complemento de fls. 220/223), bem como pelo resultado da instrução em juízo.

A autoria também foi comprovada, pelos elementos já indicados, prisão em flagrante e pelos consistentes relatos das testemunhas.

A prova oral, produzida sob o crivo do contraditório, foi no seguinte sentido:

Os policiais Flávia Fernanda Novaes da Silva e Guilherme Massaharu Maekawa confirmaram que deram cumprimento de mandado de busca no endereço indicado na denúncia, o qual é da avó do acusado, pois um televisor furtado estaria sendo utilizado no local. Durante a diligência localizaram uma arma de fogo no local. Flávia ainda ressaltou que haviam denúncias contra o acusado, inclusive de que teria esta arma, a qual não foi localizada em cumprimento de mandado de busca anterior na residência dele, sendo que então constataram que ele havia escondido a arma na casa da avó.

Interrogado, o réu disse que esta arma pertencia a seu pai, o qual faleceu. Sua mãe então levou a arma para a casa de sua avó. Disse que assumiu a propriedade da arma para sua avó não ser presa.

O conjunto de provas é suficiente para a condenação pelo crime do art. 12 da Lei 10.826/03.

Certo que policiais diligenciaram à residência da avó do acusado e localizaram a arma de fogo apreendida. Ambos narraram que prontamente o artefato foi indicado como sendo do acusado Denilson. Ainda indicaram que contra o réu já havia notícias anteriores de possível prática de tráfico de drogas e da também da propriedade de tal arma.

O réu, na delegacia, confessou os fatos, dizendo que após o falecimento de seu pai ficou com a arma (fl. 08). Em juízo, trouxe versão pouco crível, de que apenas teria assumido a propriedade da arma para sua avó não ser presa. Anoto que o réu é reincidente (e foi efetivamente preso em razão da conduta) e sua avó certamente primária; para ela, seria possível a oferta de inúmeros benefícios legais, já para o réu, pela reincidência, o regime seria (como de fato é) bem mais severo – sendo este o contexto, não faria sentido que o acusado simplesmente "assumisse" o fato. Aliás, o contexto indica ser muito mais plausível a versão acusatória, já que contra o réu pesa possível prática de outros delitos na pequena cidade de Castilho. E, ainda que assim não fosse, é certo que o réu também mantinha relação de posse com a arma de fogo, pois herdeiro do anterior proprietário e ciente de que o bem ali estava, pronto para ser utilizado a qualquer momento.

A potencialidade lesiva foi devidamente atestada, conforme laudo de fls. 143/155, sendo o crime de perigo abstrato e, assim, pouco importando o fato da arma estar, no momento, desmuniada, já que poderia ser carregada a qualquer momento e estava apta a disparos.

Quanto à tipificação do delito, o laudo complementar apontou que não há sinais de numeração suprimida – fls. 220/223.

Diante desse contexto probatório, não resta outra solução que não o acolhimento da tese acusatória apontada ao final, no sentido de condenação pelo crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03, na forma do CPP 383.

Impondo-se a condenação, resta a fixação da sanção correspondente.

Critérios para fixação da pena:

Antes de iniciar a fixação da pena propriamente dita, cabem alguns esclarecimentos sobre os critérios gerais a serem utilizados para a dosimetria, especialmente sobre a forma de cálculo das frações de aumento e diminuição. A base de cálculo será o intervalo entre a pena mínima e máxima do delito, e não a pena mínima.

Na primeira fase, na qual fixa-se a pena-base, existem oito circunstâncias judiciais passíveis de valoração. A pena sempre partirá do mínimo previsto e, a cada circunstância judicial desfavorável ao acusado, somar-se-á à reprimenda mínima cominada a fração de um oitavo (pois são oito circunstâncias), calculada pelo intervalo entre o máximo e o mínimo de pena previstos em lei para o crime em questão. A partir deste intervalo entre a pena máxima e a mínima encontra-se a fração respectiva de um oitavo para cada circunstância desfavorável.

Exemplificando-se, para melhor compreensão: se um crime tem pena mínima de 12 anos e máxima de 20 (como ocorre com o tipo previsto no art. 159, § 1º do Código Penal), o cálculo das frações é feito sobre o intervalo de 8 anos entre a pena mínima e máxima, e não sobre os 12 anos da pena mínima. A cada circunstância negativa considerada somar-se-á à pena mínima $\frac{1}{8}$ sobre oito anos, o que representa um ano.

Se não houver circunstância negativa, a pena-base será a mínima, de 12 anos; ao contrário, se todas forem desfavoráveis, a pena parte do máximo legal, 20 anos.

Tal forma possibilita ao mesmo tempo: i) controle sobre os patamares utilizados pelo julgador, que se move em espaço conferido pelo legislador por meio de critério racional; ii) proporcionalidade, pois cada circunstância terá, em regra, peso semelhante e será calculada de acordo com os patamares mínimo e máximo da pena, abarcando de forma global a gravidade do crime; iii) fixação da pena partindo sempre do mínimo legal, com a possibilidade de se chegar ao máximo previsto, caso as oito circunstâncias judiciais sejam desfavoráveis.

O critério também evita indesejáveis discrepâncias, como nos casos de crimes com pena mínima muito elevada ou diminuída. Se o cálculo partir da pena mínima, pode-se chegar a exasperações exageradas (como no caso da extorsão mediante sequestro seguida de morte, cuja pena mínima é de 24 anos) ou ínfimas (neste caso nunca se chegando perto da pena máxima cominada para o delito, como no crime de ameaça).

Ademais, permite que crimes que possuem a mesma pena mínima, mas diferentes penas máximas, justamente por serem de gravidade distinta (como a lesão corporal do caput e a figura do § 9º), sejam apenados adequadamente, cada um com sua gravidade e grau de censura já estipulados em lei. Seria injusto que para crimes de diferente gravidade a exasperação da pena-base partisse do mesmo patamar.

Via de regra, este será o critério utilizado na primeira fase. Diante da peculiaridade de cada caso as frações de cálculo poderão ser diminuídas ou aumentadas, para que se possa individualizar adequadamente a pena, de forma fundamentada (como por exemplo, nos casos de várias condenações criminais ou reincidência específica). O critério explicitado servirá sempre de parâmetro, porém não impedirá seja a pena-base fixada de modo diverso (para mais ou menos) se o caso assim recomendar (valendo isto também para a segunda fase).

Na segunda fase, na qual incidem agravantes e atenuantes, a fração usada para valoração será, no mais das vezes, de um sexto ($\frac{1}{6}$), calculado ou sobre o intervalo entre pena mínima e máxima, como acima, ou sobre a pena-base já fixada - o que for maior.

E utilizar-se-á o maior valor por uma razão simples: há uma hierarquia no sistema trifásico que deve ser respeitada. O sistema trifásico é escalonado, tendo cada fase maior relevância sobre a precedente. As circunstâncias do art. 59, valoradas pelo julgador, jamais podem preponderar sobre agravantes ou atenuantes, elevando a pena em patamar acima destas, que já foram estipuladas como mais graves de antemão pelo próprio legislador. A fração de $\frac{1}{6}$ será utilizada pois é a menor prevista para as causas de diminuição e de aumento de pena e, com isso, respeita-se novamente a hierarquia do sistema trifásico.

Por fim, como não poderia deixar de ser, as causas de aumento ou de diminuição de pena incidirão sobre a reprimenda fixada provisoriamente na primeira e segunda fases, de forma sucessiva (incidindo umas sobre as outras, em cascata), segundo entendimento preponderante nos tribunais. Do contrário poderia se chegar ou a penas

negativas, no caso de diversas causas de diminuição, ou na utilização de critérios distintos para causas de aumento e de diminuição, o que não é isonômico. Friso que o critério ora explicitado vem sendo consagrado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (HC 498586 / SP - 5ª Turma - julgado em 11/02/2020), verbis:

“2. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.

3. As agravantes não necessariamente incidem sobre o resultado da pena-base, cujo acréscimo de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativa multiplica o intervalo de pena decorrente da diferença entre a pena mínima e máxima cominadas ao tipo, para então somar à pena mínima. Portanto, as agravantes incidirão sobre a pena-base se for maior ou igual ao intervalo de pena em abstrato do preceito secundário, caso contrário, malgrado haver pena concreta dosada, as agravantes serão fixadas com parâmetro na base de cálculo das circunstâncias judiciais, sob pena de as agravantes serem menos gravosas do que meras circunstâncias judiciais”. E ainda (AgRg no REsp 1704633 / TO - 6ª Turma - julgado em 24/09/2019): “A divisão do intervalo entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato pelas oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP é um, entre outros, dos critérios que podem ser utilizados na fixação da pena-base”.

Dito isso, passo efetivamente a fixar a pena.

Na primeira fase, não vislumbro razões para exasperar a pena-base, a qual fixo em um ano de detenção.

Na segunda fase, observo que o acusado é reincidente mas confessou o crime (fl. 08), circunstância levada em conta para a formação da convicção sobre a condenação. Na esteira de já consolidada jurisprudência do STJ (HC n. 365.963/SP), neutralizam-se as circunstâncias.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição.

Sendo assim, a pena fica em um ano de detenção.

O regime inicial, tendo em vista a quantidade de pena e reincidência (fl. 88) deveria ser o semiaberto (súmula 269 do STJ). Entretanto, considerando o tempo de prisão provisória, desde já estabeleço o regime aberto para cumprimento da pena restante (CPP 387, § 2º).

Por não ser a reincidência específica (CP 44, § 3º), entendo como viável a substituição da pena privativa de liberdade, por reprimenda restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária consistente em dois salários mínimos, a serem pagos a entidade indicada pelo juízo da execução, ficando autorizado o parcelamento em até 10 vezes.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a acusação e CONDENO DENILSON DE FRANÇA MARQUES, pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo, previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003, à pena de um ano de detenção, em regime inicial aberto (CPP 387, § 2º), e ao pagamento de 10 dias-multa, calculados em seu mínimo legal. SUBSTITUO a pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária consistente em dois salários mínimos, a serem pagos a entidade indicada pelo juízo da execução, ficando autorizado o parcelamento em até 10 vezes.

Recurso em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento das custas do processo em 100 UFESPs, com as ressalvas da gratuidade, que fica aqui deferida.

Com o trânsito em julgado: i) comunique-se ao IIRGD e ii) Justiça Eleitoral, iii) anote-se a condenação (art. 372 das NSCGJ) e iv) expeça-se guia de recolhimento. Publique-se. Intime-se na forma legal.

Andradina, 08 de dezembro de 2022.

Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael
Juiz de Direito

(assinatura eletrônica)